

货方公司“发货”，境外出货方公司向被告单位付款。除上述基本模式外，还存在境外多家公司流转的情况。单纯从其内保财产本身看，确系银行自控型理财产品，具有一定的保障性和预期性，属于较为优质的抵押资产。区别于部分不良企业以利用国家支持进出口贸易外汇、信贷政策，将不良乃至虚假资产作为内保资产，造成国家外汇处于无序风险状态的严重侵害外汇秩序与安全的行为。也应看到，即便是形式上优质的内保财产，也不能保证稳赚不赔，同样有转嫁风险之虞。经国家外汇管理局数字外管平台查询，被告单位转口贸易存在“先收后支”模式，即先收到外汇，通过远期信用证再支付外汇。被告人供述、证人证言及境外汇款申请书、贸易合同、发票、海运提单、货物报关单、银行账户明细清单、微信聊天记录等证据，证实被告单位向银行故意提供虚假提单、合同等材料，虚构转口贸易背景，致使银行将外汇付至境外的事实，后再以转口收汇等形式收回资金，长期以之赚取利差。被告单位本身从事石油转口贸易，以虚假转口贸易方式逃汇套利，使贸易融资政策空转，既不利于正常贸易和实体经济的发展，也不利于促进人民币国际结算正常拓展。综上，被告单位已构成逃汇罪，鉴于内保外贷中的资产具有保障性，未造成外汇损失，在量刑上可酌予从宽考量，正是基于此，并结合从犯、认罪等情节，对涉案被告人适用缓刑。

二、犯罪主体的特征考量：基于单位犯罪特征视域下的实质与形式审查

从立法沿革来看，逃汇罪的犯罪主体呈逐渐扩大的趋势。

1997年刑法将逃汇罪的犯罪主体限定为国有公司、企业或者

其他国有单位，《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》将该罪犯罪主体确定为公司、企业或者其他单位，从仅规制国有单位到全范围的单位犯罪。随着社会发展，行政处罚和刑事司法需要关注当前逃汇行为中的个人行为。逃汇罪是刑法罪名中较少的纯正单位犯罪，与同为纯正单位犯罪的私分国有资产罪不同，仍采取双罚制，一般个人不能成为逃汇罪的主体。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，个人外汇储蓄存款，实行存款自愿、取款自由、存款有息、储户保密的原则。因此，个人携带大量外汇或外币支付凭证、

有价证券等出境，逃避海关监管，符合走私条件的，按照国家有关规定处理。① 2007年实行的《个人外汇管理办法》规定，境内个人年度购汇总额为5万美元。单位或单位与个人关联逃汇行为通常具有以下类型：一是单位利用个人年度购汇额度分拆购付汇；二是单位对外付汇无对应进口货物；三是单位虚构贸易抑或虚构转口贸易，提供或使用虚假单证方式对外付汇。②实践中，以第三种类型居多，本案便属于第三种类型，即通过虚假转口贸易、内保外贷逃汇套利。逃汇罪特殊主体的限制，并不代表个人一定不构成逃汇罪，从共同犯罪类型角度，主要包括以下三种类型：“单位+个人”“个人+单位”“单位+单位”。

就个人构成逃汇罪共犯而言，除单位内部的直接负责的主管人员和其他直接责任人员外，还可能包含个人主导性共犯、合作性共犯，在特定情况下并不是说除单位内部共犯外，一定属于帮助行为抑或合作行为，还有较为特殊的主导型共犯，下文详细阐述单位主体否定后自然人主导型逃汇行为，在此不再赘述。本案中，实际上提供帮助的还有境外的公司或其他个人，从逃汇罪的罪状描述上看，既可以是境外银行，也可以是境外单位或个人。被告人姜某某、张某某并非被告单位某公司的员工，按照某公司安排提供部分资金、注册公司，协助某公司实施逃汇行为，负责整个逃汇过程的部分环节，即主要参与内保外贷的远期信用证关联的虚假“货主”“购货”单位以及资金流转，如刑法未规定对适格主体适用从轻或者从重的处罚，

相对不适格主体一般按照从犯地位适用 刑罚，二人属合作型、协助型共犯。

以逃汇为目的设立单位抑或单位设立后以逃汇为主要业务能否认定为该罪？刑法规范、司法解释留有可供解释的空间，司法人员才能发挥主观能动性，在 罪刑法定原则基础上灵活而非机械地适用，衡平共性与特性处断规则，找到价值与目的的最佳结合点。③首先，从目的解释角度来看。单位犯罪的主体资格

①陈伶俐、于同志、鲍艳：《金融犯罪前沿问题审判实务》，中国法制出版社2014年版，第156页。

②徐子麟、任尚肖：《逃汇行为主体的刑法适用》，载《上海公安学院学报》2022年第6期。

③储槐植：《刑事一体化论要》，北京大学出版社2007年版，第159页。

否定与公司法揭破公司民事的内涵和外延均不一致，具体到逃汇罪的单位属性，其单位之范围远大于公司抑或企业法人，两者之间即便有一定重合，重合部分也不属于法律秩序统一的前置法考量范畴。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（以下简称单位解释）第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，不以单位犯罪论处。设置该条的目的主要是避免自然人通过单位名义规避刑罚制裁，而不是将主观和行为恶性更严重的犯罪行为排除在刑法规制范畴之外。其次，从体系解释角度来看。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》明确，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法所规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任，

对组织、策划、实施该社会危害性行为的人依法追究刑事责任。反向理解，不规定单位犯罪的追究个人，以单位名义实施的逃汇行为，对单位和行为人追究责任与单位解释第二条的规定并无冲突。另外，从罪责刑相适应角度来看，《中华人民共和国刑法》分则一些罪名规定的单位犯罪，只处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，而不对单位并处罚金，如《中华人民共和国刑法》第一百六十二条“妨害清算罪”。^①同样，举轻以明重，如逃汇罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员被追究刑事责任，却因某些行为人完全借用单位名义实施个人犯罪反而被豁免，无疑后者的主观和行为恶性更大，不仅违背罪责刑相适应原则，也背离民众朴素的法律观念。

概言之，逃汇罪犯罪特征中的犯罪主体需要有单位之形式要件，而实质上 即便系属单位解释第二条的排除情形，亦不能否定逃汇罪成立；同时，在量刑 上应对后者较之前者从严惩处，既符合罪责刑相适应原则，也更契合刑罚的社会价值导向。

三、定罪量刑评判要素与标准：不唯犯罪数额论的定性定量参照系衡量

司法实践中，在数额犯罪没有规定上档标准的情况下，出于关联性、相当性考量，一般参照同章节近似罪名的上档标准的倍数作从宽考量。逃汇罪的同

①王爱立主编：《中华人民共和国刑法释义》，法律出版社2021年版，第57页。

章节罪名中入罪到上档情节五倍居多，考虑上述因素，并结合社会发展情况以及逃汇数额的累积性特征，更宜从严掌握上档的数额标准。本案中，被告单位涉案数额近5亿美元，达到入刑标准的100倍，持续时间长，不仅虚构交易，还合作设立境内外协作单位等，足以认定系数额巨大。

外汇损失是否为逃汇罪的罪质及定量要素？如前文所述逃汇罪系秩序犯，客观上严重侵害了外汇管理秩序符合该罪构成要件，成立该罪并不要求造成外汇损失。换言之，造成外汇损失不是逃汇罪的罪质要素。无论是违反国家规定擅自将境内外汇存放境外，还是将境内的外汇转移到境外，实际上逃汇行为中的用而不损和既用又损之间，秩序危害程度孰重孰轻不言而喻，造成损失是逃汇更为严重的后果之一，体现为刑法规制的提前，一定程度上旨在以规制行为来防范更为严重的造成外汇损失的结果情形。该罪名罪状描述中既列举了数额较大、数额巨大，也列举了数额巨大相对应的其他严重情节，该“其他严重情节”应当包括造成外汇损失要素，该理解不仅符合该罪名的规制目的，也不超出刑法预测范围。因此，在上档情节判断中应当考量造成外汇损失的情节。当然，在入刑标准上虽罪状描述仅有数额较大，但外汇损失同样可以成为量刑的考量因素，并全面评价行为性质、犯罪手段、主观动机，以之构建全面、完备的量刑参照。本案中，被告单位虽虚构转口贸易，结合其先支后付的犯罪手段，具有相对可控性、相当兑现性资产作底的内保外贷模式，无证据证实造成外汇储

备量减少，抑或造成外汇损失，鉴于此在量刑上对被告单位尤其是各被告人予以适当宽宥性考量。

综上所述，被告单位、被告人虚构转口贸易，致境内外汇被非法转移至境外，数额巨大，人民法院以逃汇罪定罪量刑，是妥当的。

编写人：广东省广州市天河区人民法院 罗 成

(五) 金融诈骗罪

42

非法集资行为人主观目的及客观行为特征的认定

—— 许某集资诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05刑终357号刑事裁定书

2. 案由：集资诈骗罪

【基本案情】

2019年1月至2021年10月18日，被告人许某经营某通讯店并成为某通讯公司晋江分公司签约经销商，其虚构向某通讯公司投资“刷单冲业绩赚积分”的事实，并以每个月2分至2.8分的高额利息为诱饵，诱骗被害人尤某等19名被害人进行投资，骗取上述被害人钱款共计2495593.59元。2021年12月7日，公安机关抓获被告人许某，从其处扣押手机1部、账本25本、通讯店营业执照1本、农商银行卡和招商银行卡各1张。

【案件焦点】

1. 本案被告人许某主观上是否具有非法占有目的；2. 被告人向多人集资是否符合非法集资诈骗犯罪“公开性”要件。

【法院裁判要旨】

福建省晋江市人民法院经审理认为：被告人许某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人许某归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。综合考虑被告人许某的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，判处被告人许某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币20万元；责令被告人许某退赔各被害人相应经济损失共计人民币2495593.59元；暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部及银行卡2张，由扣押机关予以没收，上缴国库。

一审宣判后，被告人许某提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：许某的上诉意见不能成立，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

被告人许某主观上是否具有非法占有目的，以及本案实施行为是否具有非法集资犯罪的四个特征直接关系到其行为定性。是否具有非法占有目的是区分其行为是否具有诈骗性质的重要标准；行为人如在非法占有目的的支配下实施骗取他人财物的行为，那么该行为是否符合非法集资犯罪的四个特征是区分集资诈骗罪与普通诈骗罪的关键因素。

一、关于被告人许某主观非法占有目的的认定问题

“非法占有目的”系财产犯罪的重要构成要件，其系行为人的一种主观意图，蕴藏于行为人的客观行为之中。在司法实务中，对于这种主观意图的探究，一般依托于行为人的供述，再以其他客观证据进行佐证，但在行为人不主动供述的情况下，

只能借助外在的客观情形加以推定，一般是通过客观上实施的行为进行推定。关于非法集资犯罪，集资行为人对集资财物在主观上是否具有非法占有目的，也是司法实践中的一个难点，对此，《最高人民法院关于审理非

法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款列举了七种可以认定为“非法占有为目的”的情形，即使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；(3)携带集资款逃匿的；(4)将集资款用于违法犯罪活动的；(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；(7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的，并以兜底形式规定了“其他可以认定非法占有为目的的情形”。从内容上看，构成集资诈骗罪的情形主要落脚在无法返还或逃避返还资金上，以上规定系根据司法审判实践经验总结而来的，系采用司法推定的方式认定主观非法占有目的，从总体上来讲，推定行为人主观上是否具有非法占有目的，主要是根据集资后资金的运用方式作为认定标准。但在司法实践中，在无法归还集资款的情况下，具体情形可能更为复杂，还是应该综合判断，不能单从无法返还这一事实本身推断行为人主观上具有“非法占有目的”，否则会混淆集资诈骗罪与非法吸收公共存款罪的界限，使“非法占有目的”在司法判断中流于客观实质化。笔者认为，在司法实践中，认定是否具有非法占有目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人的供述判断，而应当根据案件具体情况具体分析。就本案而言，被告人许某并没有雄厚的经济基础，在明知

自己没有实际 归还能力的情况下，向被害人虚构联通刷单冲业绩业务并许诺按期给予高额固 定投资回报且到期还清投资本金，并让被害人通过“口口相传”的方式介绍他 人投资或通过被害人相互介绍，欺骗被害人向其投资，并采用拆补的方式将资 金用于归还之前的投资款、利息，且挪用钱款用于家庭开支，没有实际用于其 所宣称的投资项目，最终导致他人的巨额钱款无法返还，故可以认定被告人许 某主观上具有非法占有的故意，其实施的系诈骗行为。

本案对被告人许某主观上具有非法占有目的的认定系以司法推定的方式进 行认定，但司法推定允许反驳，推定的基础事实与推定结论之间并不具有必然

的联系，因此，司法推定必须严格遵守一定的规则，否则有沦为司法擅断的危险。大致说来，司法推定应该遵守以下几项规则：已知事实必须确定，并且一般不能是一个推定的事实；司法推定必须符合经验法则、社会常理；充分保障行为人的反驳权。司法实践中，对于集资人是否具有非法占有目的，“不推而定”是一个比较常见的极端，但是另一个极端也不容忽视，即轻易否定集资人的非法占有目的，如集资人制订了非常详细的还款计划，但这并不表明集资人一定不具有非法占有的目的，因为这完全可能是集资人的反侦查措施。因此，司法机关必须综合各种事实，设身处地、身临其境地考察集资人的所作所为，全面审查各种证据，尤其是集资人关于自己犯罪目的的供述，找出其中的矛盾之处，并试着从正反两个方面不断对这些矛盾进行合理的解释，进而作出科学的判断。

二、关于被告人许某的行为定性问题

本案被告人许某系在非法占有主观目的的支配下实施了骗取他人财物的行为，其行为特征决定了其行为定性问题，本案公诉机关原指控被告人许某构成诈骗罪，后经过庭审后，公诉机关认为被告人许某的行为符合集资诈骗罪的构成要件，故变更起诉指控被告人许某构成集资诈骗罪。

集资诈骗罪具有四个行为特征即“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”。本案中，被告人许某未经有权机关批准对外吸收数额巨大的款项，其行为违反了国家的金融管理法规，符合“非法性”特征；被告人许某采用以高回报率为诱饵进行非法集资，向被害人承诺的分红远远高于银行同期存贷款利率，且承诺返本付息，已经超出了正常市场经济规律可以承受的范畴，符合“利诱性”特征；被告人许某虽然没有通过新闻媒介、在公开场所张贴宣传材料等方式宣传其投资模式，但其系通过被害人向其他人员宣传其投资模式，此系一种口口相传、以人传人的宣传方式，通过口口相传向社会公众非法集资的，是一种变相的向社会公开宣传形式，其行为符合“公开性”的特征；被告人许某系通过亲友口口相传、以人传人的公开宣传方式进行宣传，实质上要求、希望并放任亲友向社会介绍，通过亲友间接向社会公众吸收资金，不影响其向社会公

众吸收资金的认定，符合“社会性”特征。综上，被告人许某以高额回报的方式非法吸收社会上的资金的行为影响了金融资金的流向，破坏了国家的金融管理制度；其虚构投资项目以资金用于投资可获得高额回报的名义诈骗他人钱财，非法占有他人资金，严重侵犯了公私财产所有权，其行为符合集资诈骗罪的四个要件，应以集资诈骗罪论处。

编写人：福建省晋江市人民法院 廖文斌

虚拟“矿机”租赁挖币返利模式的行为定性

—— 贾某某集资诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03刑终225号刑事裁定书

2. 案由：集资诈骗罪

【基本案情】

2019年年底，被告人贾某某委托网络科技有限公司负责人刘某制作L平台，该平台投资方式为通过A币在该平台购买“矿机”挖矿产生K币。投资人也可通过推荐其他人进行投资获得推荐奖励获取投资利润。

被告人贾某某在明知K币无法在二级市场实际交易且无任何价值的情况下，在微信群内以高额回报为诱饵对该平台进行虚假宣传，骗取投资人信任。同时，被告人贾某某自行调控后台数据控制K币与A币的兑换比例、自行控制K币的涨跌，吸引投资人投资。被告人贾某某对投资人提现申请设置审核，自行控制投资人提现。2020年11月，被告人贾某某以系统升级为由在后台设置

禁止提现，至2021年1月，L平台无法登陆导致大量投资人损失，被告人贾某某共骗取244名投资人37012842.37元人民币。其中，用于购买“矿机”、支付矿场的电费、“矿机”的托管费及维护费共计人民币30933505.76元。

另查明，2020年10月，被告人贾某某向李某1银行账户转账人民币70万元用于购买平谷区某小区房产。

2021年4月21日，被告人贾某某被公安机关查获。

【案件焦点】

1. 虚拟货币是否符合非法集资犯罪对募集对象的要求，贾某某的行为是否构成非法集资犯罪；2. 贾某某客观上是否使用了诈骗方法，主观上是否具有非法占有目的。

【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为：被告人贾某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。被告人贾某某给集资参与人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押、查封之款、物，依法处理。故，判决：被告人贾某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币50万元。

一审判决后，被告人贾某某不服，提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：上诉人贾某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市平谷区人民法院根据贾某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

虚拟“矿机”租赁挖币返利模式，是指行为人自建虚拟货币平台出租虚拟货币挖“矿机”，投资人将人民币兑换为主流虚拟货币（以下简称主流币）投入到平台上租赁虚拟“矿机”挖出仅能在平台内部流通的虚拟货币（以下简称内部币），平台往往会承诺“矿机”产出的内部币会按照一定的比例上涨或承诺高额回报，诱导投资人进行投资。这一行为模式在本质上属于变相ICO（首次代币发行），司法实践中可能会涉嫌组织、领导传销活动罪，非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等。本案中，并不存在收取或变相收取入门费的情形，且参与者并非“直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”，故该行为不构成组织、领导传销活动罪，对此各方均无异议。本案争议焦点主要有两点：（1）虚拟货币是否符合非法集资犯罪对募集对象的要求，贾某某的行为是否构成非法集资犯罪；（2）贾某某客观上是否使用了诈骗方法，主观上是否具有非法占有目的。

一、虚拟货币系作为非法集资过程中法定货币的价值载体，符合非法集资犯罪对募集对象的要求

2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》首次明确规定非法吸收公众存款罪的规制对象是“资金”。针对虚拟货币是否属于解释中规定的“资金”这一问题，司法实践中主要存在两种观点：第一种观点认为，根据文义解释，虚拟货币不属于“资金”范畴，只有当犯罪行为对象针对法定货币时，才会破坏金融秩序。第二种观点认为，主流虚拟货币已成为现金的替代品，属于广义的

“资金”范畴。笔者认为，虚拟货币 虽然不属于资金，但仍能成为非法集资犯罪的对象。理由如下。

其一，从本案“矿机”租赁挖币模式的本质看，其本质为变相ICO，虚拟货币系作为吸收人民币的媒介或渠道。所谓ICO，学界一般称其为“首次代币 发行”或“代币首次公开发售”，是一种依托于区块链技术，利用区块链去中心化的特征以及分布式账本的特点，在区块链上记录交易过程、发行自己的数字代币，向不特定的投资者募集数字货币，再将数字货币兑换成法定货币的集

资行为。①通俗来讲，就是集资者以自己新发行的虚拟货币作为回报，吸收不特定网民所持有的主流虚拟货币的行为。本案中，投资人的投资模式为通过人民币在APP上购买A币，用A币在L平台租赁虚拟“矿机”挖矿产生K币，再把K币转换成A币，卖出A币变现。该“矿机”租赁挖币返利模式中，投资人投入资金存在一个转化过程，即“人民币—主流币—内部币”，投资人赎回资金过程为“内部币—主流币—人民币”。由此可见，虽然平台吸收的是虚拟货币，不属于法定货币或资金，但是虚拟货币只是吸收资金的媒介或道具，其最终是通过人民币兑换实现自身的价值。因此，人民币的价值是通过附着在虚拟货币上在投资人和集资者之间流动，虚拟货币在非法集资过程中是作为法定货币的价值载体存在，当然符合非法集资犯罪对募集对象的要求。

其二，从维护金融市场安全角度来看，认可虚拟货币符合非法集资犯罪对募集对象的要求有利于保障金融安全。我国在立法和司法实践中已经注意到了虚拟货币市场存在较大风险隐患并极大限制虚拟货币市场发展。2022年修正后的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第八项明确规定以虚拟货币交易等方式非法吸收资金的可以构成非法吸收公众存款罪。然而，在司法实践中，总有一些不法分子利用刑事规制的空白，利用虚拟货币实施非法集资活动。因此，当我们探讨如何保护金融管理秩序和维护金融市场交易安全时，不可能亦不应当对虚拟经济置之不理，固守货币本位立场的非法集资犯罪并不适应当前经济发展现状。

二、被告人的行为符合非法集资行为的“四性”特征

被告人的行为构成集资诈骗罪的前提条件是符合非法集资的四个基本要件，即非法性、公开性、利诱性、社会性。贾某某组建多个微信群，在微信群内公开宣传L平台，并通过网络宣传、线下活动等方式向不特定对象公开推介，以高额回报、返本付息等为诱饵吸引投资人投资，其行为当然具有公开性、利诱性和社会性。判断“矿机”租赁挖币返利模式是否具有非法性应当进行实质判

①何隽铭：《ICO商业模式法律性质分析及监管模式优化——基于九国ICO监管现状》，载《上海金融》2018年第2期。

断和个案分析。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定是构成非法集资类犯罪的前提条件。关于国家金融管理法律规定的内涵，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第一条之规定，国家金融管理法律规定原则上以国家金融管理法律法规为依据，但对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件亦可作为参考依据。本案中，贾某某的行为具有非法性主要体现在两个方面。

第一，《关于防范代币发行融资风险的公告》第一条、第二条指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。本案中，被告人贾某某通过自建虚拟货币挖矿的L平台，在平台上发行K币，承诺投资K币可获得高额回报，同时投资人可以在平台上花费K币购买商品或者服务，本质上相当于在L平台上创设了一种虚拟内部币，代替了法定货币的付款义务。因此，贾某某的行为具有非法性。

第二，根据《中华人民共和国商业银行法》第十一条规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。经查，L平台钱包地址为以太坊公链自动生成，钱包地址入金后会自动转入归集地址，归集地址也是以太坊公链自动生成。故，贾某某在“矿机”租

赁 挖币返利模式中事实上形成了资金池，贾某某可以实际控制资金，符合“未经 有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金”的非法性特征。

三、被告人主观上具有非法占有目的，应认定为集资诈骗罪
针对贾某某主观是否具有非法占有目的争议较大，一种观点认为，贾某某 将投资人的大部分资金用于购买实体“矿机”进行挖矿、缴纳“矿机”电费管 理费等，足以证明其主观上不具有非法占有目的，贾某某的行为构成非法吸收

公众存款罪。另一种观点认为，贾某某将大部分钱款用于投资实体“矿机”并不能否定其主观上具有非法占有目的，贾某某的行为构成集资诈骗罪。笔者认同第二种观点。

第一，L平台发行的内部币不具有真实性和价值性。贾某某隐瞒其系L平台的实际控制人，虚构L平台具有国外背景和某集团投资背景。贾某某虚构K币的实际价值，通过在后台操作充值电话费、加油卡等行为，虚构K币可以在二级市场实际交易的事实，但实质上K币根本不具有公允价值，且只能在平台内部流通，无法在第三方平台自由流转。贾某某通过调控后台数据控制K币的产生数量以及K币和A币的兑换比例，控制K币的涨跌，营造出K币价格呈上涨趋势的假象，骗取投资人进行投资，后自行在后台设置禁止提现，造成集资参与人重大财产损失。

第二，贾某某对资金使用的决策极不负责任，造成资金缺口巨大。根据被告人贾某某供述，其前期将集资款项投资于虚拟交易平台，后期用于购买实体“矿机”“挖矿”。对此，贾某某自述其长期从事虚拟货币交易，其应明知我国对虚拟货币及“挖矿”活动的风险防范、整治政策，而贾某某未经有关部门批准，建立L平台向社会不特定公众吸取资金，并将数额巨大的集资款项投资于虚拟交易平台或用于购买实体“矿机”“挖矿”，其行为无视法律风险、收益风险，体现了对资金使用决策的极不负责任，并最终导致集资参与人损失巨大。

第三，贾某某存在隐匿财产、逃避返还资金的行为。根据在案证据显示，贾某某实际控制的L平台无法提现后，其向集资参与人隐瞒自己是平台实际控制人的事实，谎称自己是受害人，要带集资参与人到天津维权。在L平台崩盘后，贾某某未及时退赔，反而欲通过新的平台继续吸收资金，维持非法集资骗局。在被公安机关查获后，贾某某经多次讯问，均否认自己与L平台的关系，拒不交代集资款项去向。直到公安机关通过案外人才得知其购有大量实体“矿机”的事实。同时，贾某某在一审期间通过辩护律师告知其母亲找案外人处置部分“矿机”，变卖款项亦挪作他用。

综上，本案中的投资人并非“直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返

利依据”，可首先排除组织、领导传销活动罪的适用。“矿机”租赁挖矿返利本质上为变相ICO，虚拟货币系法定货币的价值载体，符合非法集资犯罪对募集对象的要求。具体判断行为人构成非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪时，应当通过审查平台发行的虚拟货币是否具有真实性和价值性、行为人是否对资金使用决策极不负责、行为人是否存在隐匿财产或逃避返还资金的事后行为等因素综合判断行为人主观上是否具有非法占有目的，确保案件定性准确，量刑适当。

编写人：北京市第三中级人民法院 王世洋 于晓航

销售数字藏品时借用合法经营形式 非法吸收公众资金构成集资诈骗罪

—— 张某某、刘某集资诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市闵行区人民法院(2023)沪0112刑初1200号刑事判决书

2. 案由：集资诈骗罪

【基本案情】

2022年6月，被告人张某某起意并与被告人刘某商议利用二人实际经营的某公司设立某平台，将购买或从网络免费下载的图片包装为“数字藏品”在该平台销售。某平台具体运营由被告人张某某全权负责。

被告人张某某指使他人通过网络渠道，面向社会不特定对象推广某平台上的“数字藏品”，谎称该平台系与某文化协会联合打造，并与多家博物馆合作联合发布“数字藏品”，虚假承诺该平台将定期以双倍价格回购特定“数字藏

品”，购买者还可享受未来平台手续费分红、元宇宙土地优先购买权等权益，虚构购买特定“数字藏品”可合成稀有高溢价“数字藏品”，购买“数字藏品”盲盒进行积分冲榜可兑换现金、手机、名酒等功能及玩法，开放二级市场交易，营造购买该平台“数字藏品”可获高额回报的假象，吸引公众下载某平台APP，注册账户并充值、购买、交易“数字藏品”。该平台用户资金均进入被告人张某某所实际控制的账户后进行流转。

同年7月下旬，被告人张某某还通过控制他人账户、雇佣外包炒作团队，在某平台的二级市场中自买自卖，虚增“数字藏品”交易量及价格，营造该平台“数字藏品”交易火爆且有升值空间的假象，进一步吸引用户交易“数字藏品”。

其间，被告人张某某陆续将用户支付的钱款提现并与被告人刘某分赃，同时仍谎称某平台将与某1公司开展合作，后续藏品均在某1公司上架。同年9月底，被告人张某某停止服务器续费致使某平台被关闭，造成用户无法提现、无法查看“数字藏品”。同时，被告人张某某还解散相关网络群聊。经审计，该平台吸收数千名用户资金共计人民币134万余元，造成被害人损失共计41万余元。

2023年2月23日，被告人张某某、刘某被公安机关抓获，到案后均如实供述上述事实。在审理期间，被告人张某某、刘某均自愿认罪认罚并全额退赃。

【案件焦点】

两名被告人的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

上海市闵行区人民法院经审理认为：被告人张某某、刘某构成集资诈骗罪，理由如下：（1）从涉案“数字藏品”的来源，欣赏、收藏价值及其在某平台上无具体应用场景等因素综合来看，被告人张某某、刘某并未提供实质意义上的商品作为用户支付资金的对价。该平台用户购买上述“数字藏品”以获取预期收益为目的。用户购买、出售上述“数字藏品”并提现的行为实质为投资理财行为。二名被告人利用某平台归集、沉淀资金，形成流动资金池，其行为实质是以商品回购、二级市场交易等方式变相吸收公众资金。（2）被告人张某某指

使他人通过互联网的各种渠道向社会不特定的对象公开宣传某平台上的“数字藏品”，所吸收的资金亦来自不特定的公众。其行为带有明显的公开性、社会性特征。(3)被告人张某某虚构事实、隐瞒真相，导致他人产生错误认识而投资购买某平台发行的“数字藏品”，其行为带有明显的欺骗性、利诱性特征，主要体现在以下几个方面：①虚构“数字藏品”来源并虚假承诺返利。被告人张某某指使他人虚假宣传，谎称该平台系与亚洲文化协会联合打造，并与多家博物馆合作联合发布“数字藏品”，实际上则利用从网络免费下载的图片或者从他人处购买的普通绘画作品来制作“数字藏品”。其虽承诺定期以翻倍价格回购特定“数字藏品”（创世勋章）、购买“数字藏品”盲盒进行积分冲榜可兑换高价礼品等利益，但最终均未兑现。②虚构“数字藏品”升值预期。被告人张某某利用某平台等渠道宣称用户购买特定“数字藏品”可合成稀有“数字藏品”，开放二级市场供用户交易，给用户强烈的升值预期。③虚假交易营造升值假象。被告人张某某在二级市场通过自买自卖的方式，虚增“数字藏品”交易量及价格，营造该平台“数字藏品”交易火爆且有升值空间的假象，进一步吸引被害人交易“数字藏品”。本案多名被害人的陈述及报案材料亦能证实，被害人系受高额回报虚假宣传的影响而投资购买涉案“数字藏品”。从本案侵犯的法益来看，二名被告人的行为不仅破坏了金融秩序，而且侵犯了被害人的财产权。(4)二名被告人具有非法占有的目的。被告人张某某提取被害人支付的钱款与被告人刘某瓜分，并关闭某平台，造成被害人无法提现、无法查看“数字藏品”。据此，足以认定二名被告人具有非法占有的目的。据此，判决如下：

一、被告人张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元；

二、被告人刘某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10万元；

三、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔，所得款项按比例发还各被害人。

案件判决后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于两名被告人的行为定性。集资诈骗罪与诈骗罪属于特殊罪名与普通罪名的关系，两罪都表现为实施欺骗行为使他人陷入错误认识后处分财产，区分二罪的关键在于，行为人是否利用诈骗的方法非法集资。

非法集资的非法性具体表现为未经有关部门依法批准借用合法经营的形式吸收资金。在审判实务中，行为人以确定的存款期限、利率，面向社会公众吸收存款的形式比较容易识别，但借用合法经营的形式变相吸收公众资金的具体表现形式复杂多样。其行为到底是正常经营活动还是以经营之名行非法集资之实，往往难以分辨，尤其是以前沿科技为载体的经营模式更具迷惑性。在正常的商品经营活动中，销售方在获得资金的同时也为购买者提供了相应价值的商品或者服务，二者属于等价交换。在金融活动中，出资方并不是以得到等价商品或者享受服务为目的，而是为了获取资金的未来收益。接受投资的一方并无实质意义的商品或者服务作为对价提供给投资人，出资方预期收益具有很大的不确定性。区分正常经营活动与融资行为主要在于两个方面：一是有无真实的商品或者服务内容；二是是否以未来的回报为目的。

本案两名被告人通过销售“数字藏品”、用户充值、提供交易平台等方式从平台众多注册用户处获得资金，从表面上看属于正常的商品交易行为，但实质上属于借用合法经营形式变相吸收公众存款。具体理由是：

第一，本案两名被告人从用户处获取资金时，未向用户提供实质意义上的商品。

“数字藏品”是一种基于NFT（区块链技术）而产生的加密数字资产。“数字藏品”业态具体表现为通过区块链、智能合约等技术手段，将数字内容确定为特定的交易对象并在NFT交易平台进行交易流转。在实体作品交易中，买家可以直接取得实体作品的所有权，而“数字藏品”交易则体现为数字资产法律关系的链上交易。“数字藏品”交易作为新兴文化业态，推动了数字艺术市场的发展和繁荣，逐渐成为虚拟世界（元宇宙）中的重要财产形态。但是，由于“数字藏品”属于非标准化的数字资产，尚未形成公认的价值确认体系，价格

